

1500552-60.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500552-60.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-60.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073742/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23659841 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1275/22/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2073742 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YÚRI LIMA DE MELO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

GUTEMBERG ARAÚJO OLIVEIRA e YÚRI LIMA DE MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de março de 2022, por volta das 20 horas, na Estrada do Ponei Club, nº 1.000, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e comarca de São Bernardo do

Campo/SP, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, drogas consistentes em 2,6g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 14 invólucros plásticos; 7,21g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 55 eppendorfs; 10,78g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 57 invólucros plásticos; e 26,11g de cocaína, acondicionadas em 40 invólucros plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 16 e laudo de constatação de págs. 18/21.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, os acusados traziam consigo, para fins de comercialização, cento e sessenta e seis embalagens individuais de drogas.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Estrada do Ponei Club, bairro dos Alvarengas, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, quando na altura do numeral 1.000, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita no interior de um veículo, razão pela qual desembarcaram da viatura para realizar abordagem.

Nesse instante, o policial que conduzia a viatura visualizou os acusados mais à frente, correndo a pé, e avisou os demais integrantes da equipe policial, que saíram no encalço deles.

Então, os policiais constataram que GUTEMBERG parou próximo a um automóvel estacionado na via e escondeu um objeto.

Os acusados foram capturados e durante revista pessoal, os policiais encontraram a quantia de R\$ 81,00 (oitenta e um reais) na posse de GUTEMBERG.

Em seguida, eles procederam a buscas nas proximidades dos veículos e localizaram entre o pneu traseiro do lado esquerdo e o para-lamas daquele automóvel que GUTEMBERG se aproximou, uma pochete, dentro da qual havia catorze pequenas porções de maconha, cinquenta e cinco eppendorfs contendo maconha, cinquenta e sete invólucros plásticos com crack e quarenta invólucros plásticos contendo cocaína, além da quantia de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Indagados, YURI assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e confessou a traficância, ao passo que GUTEMBERG afirmou que apenas realizava a vigilância do local, atuando como informante.

Nestas circunstâncias, eles foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes por parte dos acusados.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial às págs. 06/147. Notificados (pág.202 e 209), os réus ofertaram defesa preliminar (pág.213) Recebida a denúncia às págs. 214/215, os réus foram citados (pág.218). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se os réus.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, elevando-se a pena base em razão da quantidade de droga. Quanto ao réu Gutemberg, postulou reconhecimento da reincidência, afastamento do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena. No tocante ao acusado Yuri, destacou as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto.

Foi deferida a conversão dos debates em memoriais, requerida pela defesa, diante da

'colidência de defesa' (págs.221/224).

Em memoriais (págs.229/233 e 234/239), a defesa requereu a absolvição dos acusados por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão à pág. 16 (pochete, dinheiro e droga); nos laudos de constatação às págs.18/21 (copiado às págs. 175/178), químico-toxicológico às págs.179/181 e 184/185 e pericial às págs.182/183 (pochete), bem como no comprovante de depósito de pág. 118.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (págs.9 e 10), em Juízo o acusado GUTEMBERG negou a prática do delito e apontou YURI como o traficante que lhe venderia droga na data do fato:

Retornava do trabalho e parou na 'biqueira' para comprar uma porção de maconha. Pediu a droga ao réu YURI, traficante no local, que se dirigiu a um automóvel para apanhar a porção solicitada. Não a recebeu porque, neste momento, policiais militares realizaram a abordagem. Não correu e foi falsamente incriminado. Não conhecia Yuri.

A negativa de autoria foi afastada não apenas pela prova colhida em instrução, mas pelo próprio corréu YURI que, ao confessar o seu envolvimento no tráfico de droga, confirmou que agia em comparsaria com Gutemberg:

Estava na posse da droga localizada no interior da pochete, sendo o responsável pela venda no local. Praticava o crime pela primeira vez. O dinheiro localizado no interior da bolsa era oriundo da venda das substâncias entorpecentes. Gutemberg agia como 'olheiro', realizando a vigilância do ponto de droga. Conhecia Gutemberg havia pouco tempo e sabe que ostenta passagens pelo crime de tráfico de droga. YURI confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova.

Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

"Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A prática do crime pelos acusados vem demonstrada, sob o crivo do contraditório, nos depoimentos dos policiais militares Alan Crivellaro e Antonio Rafael Mota Braga. Em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida acerca da veracidade da hipótese acusatória:

Realizavam patrulhamento pelo local do fato, conhecido ponto de tráfico de droga, e resolveram abordar condutor de veículo parado no local em atitude suspeita. Ocorre que, ao desembarcarem da viatura, os réus, que estavam parados no local, correram juntos e na mesma direção ao notar a presença policial.

Suspenderam aquela primeira abordagem (e o condutor do automóvel deixou o local), partindo no encalço dos acusados, que se esconderam entre dois automóveis. O policial Alan, neste momento, visualizou GUTEMBERG escondendo algo na roda traseira de um destes carros.

Realizada a abordagem, em poder de GUTEMBERG foi localizada a quantia de R\$81,00 em dinheiro.

Na roda do carro foi apreendida uma pochete, dentro da qual foram localizadas porções individuais de crack, cocaína e maconha em quantidade típica de tráfico, além de dinheiro.

Inquiridos, os réus confessaram a prática da mercancia ilícita no local. YURI apresentou-se como o responsável pela venda e, GUTEMBERG, aduziu que realizava a vigilância no local.

Os policiais não conheciam YURI.

O policial Alan disse que já havia abordado GUTEMBERG naquele ponto, em data anterior, mas nada ilícito havia sido apreendido em poder dele.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial aos réus, que sequer conheciam, imputando-lhes falsamente crime.

Nesta linha: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

A ausência de qualificação de civis como testemunhas, por si só, não leva à absolvição da agente, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado.

Além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (69 porções de maconha, e 40 porções de cocaína e 57 porções de crack), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro trocado, além das circunstâncias da abordagem (réus estavam em conhecido ponto de droga, buscaram fuga ao notar presença policial e ocultaram droga em automóvel diante da iminente abordagem), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do

citado Diploma.

Consigne-se que, embora os réus não tenham sido presos enquanto efetuavam a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o tráfico, crime permanente, é delito de ação múltipla ou de conteúdo variado. Consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada aos acusados na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelos réus.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício dos acusados, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta, YURI declarou que estava de 'cabeça quente" e "cheia". Nada mais. Declarou que não estava sob efeito de droga.

GUTEMBERG, ao negar o delito, declarou-se mero usuário e afirmou que não chegou a apanhar a droga que pretendia usar.

Preso desde março p.p, não há nos autos relato de alteração comportamental ou de saúde de Gutemberg, quadro que não se coaduna com o de um dependente químico.

Outrossim, a defesa não requereu a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elemento para determinação da diligência de ofício.

E em Juízo o réu ofertou raciocínio coerente, fornecendo, com clareza, detalhes sobre o delito e ação policial. Não se verificou a existência de indício mínimo acerca de comprometimento da incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e/ou determinar-se de acordo com este entendimento.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

O policial militar Alan, inclusive, informou que os acusados não apresentavam raciocínio regular e coerente.

Portanto, os réus realizaram conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado GUTEMBERG, que ostenta desfavoráveis condições subjetivas.

Pesa contra o acusado condenação anterior e irrecorrível por tráfico de entorpecentes (autos nº 0000356-14.2015.8.26.0537, que tramitaram na 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017, cf. certidão criminal de págs. 55/58 e folha de antecedentes de págs. 59/62).

A quantidade de droga apreendida (176 porções individuais), de natureza diversa (maconha, cocaína em pó e crack) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. O crime é de perigo abstrato. Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a "natureza" (ou "qualidade") e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos

traficantes ("HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".

Os antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito não podem ser olvidados nesta etapa e elevam a pena base do réu em 1/5, o que perfaz 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

De outra parte, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado YÚRI, primário e sem antecedentes criminais. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (a quantidade de substância entorpecente apreendida será considerada na terceira etapa da dosimetria, sob pena de bis in idem).

Não incidem agravantes em relação a YÚRI. Embora presente a menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art.65, I e III, 'd'), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Reincidente específico (autos nº 0000493-25.2017.8.26.0537 - 5ª Vara Criminal de SBC. Trânsito em julgado em 31/01/2018, cf certidão de pág. 55/58 e F.A. de págs. 59/62), elevo a pena de GUTEMBERG em 1/6, fixando-a em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Não incidem atenuantes.

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não incidem causas de aumento de pena.

Com relação a GUTEMBERG, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O RÉU É REINCENTE ESPECÍFICO.

O tráfico privilegiado, contudo, deve ser reconhecido em favor do réu YÚRI, presentes os requisitos legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminoso ou integra organização criminoso. Todavia, há óbice à aplicação do índice redutor máximo. Com efeito, não é possível olvidar a variedade, natureza e razoável quantidade de droga apreendida - 176 porções (69 porções de maconha, e 40 porções de cocaína e 57 porções de crack).

O benefício de redução de pena previsto no mencionado §4º não foi instituído pelo legislador para atuar como redutor máximo automático das sanções correspondentes ao tráfico de droga no grau máximo.

Teve o escopo de disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento de individualizar as reprimendas correspondentes a esse delito.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (maconha, crack e cocaína) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a

saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato.

Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena em 1/2, o que perfaz 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado.

A jurisprudência majoritária acolhe o entendimento de que tais circunstâncias devem ser apuradas nesta etapa da dosimetria da pena, método compatível com a melhor hermenêutica e mais próximo da correta interpretação e aplicação do Direito como ciência (Apelação Criminal nº 0003571-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 11/05/2010; Apelação Criminal nº 0074313-35.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/08/2011; Apelação Criminal nº 0011319-96.2007, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 18/10/2012).

Ainda nessa linha: AgRg no HC 209930/ES, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgado em 18/10/2012; HC 244726/ES, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/10/2012.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

Fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada para o réu YURI.

Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.

Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”) trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)”

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o "tráfico privilegiado" como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos "apresentam contornos menos graves e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência".

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados "dois pesos e duas medidas".

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber:

A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado "tráfico privilegiado", conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos para YÚRI, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto. Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal.

YÚRI é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas. Confessou a prática do crime. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Cumpra-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Na espécie, YÚRI admitiu que era o responsável pela droga que vendia no local, apreendida em quantidade razoável, o que torna a conduta mais censurável. O dinheiro encontrado na pochete era oriundo da venda da droga, conforme admitido pelo próprio acusado em audiência, de modo que Yuri estava na posse de quantidade ainda maior que a apreendida no momento da abordagem policial. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

Para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada para o réu GUTEMBERG, o



regime FECHADO.

É o adequado para consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as desfavoráveis condições subjetivas apresentada pelo agente, que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O acusado ostenta duas condenações anteriores e irrecorríveis justamente pelo crime de tráfico de droga (autos nº 0000356-14.2015.8.26.0537 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017. E autos nº 0000493-

25.2017.8.26.0537 - 5ª Vara Criminal de SBC. Trânsito em julgado em 31/01/2018.

Audiência admonitória em outubro de 2020, cf certidão de pág. 55/58 e F.A. de págs. 59/62).

Voltou a delinquir em breve espaço de tempo, quando ainda cumpria as condições de regime aberto pela última condenação, reiterando a ação criminosa, o que demonstra que o réu faz do crime equiparado a hediondo o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido na vida de GUTEMBERG.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os acusados:

a) GUTEMBERG ARAUJO OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

b) YÚRI LIMA DE MELO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

YÚRI respondeu ao processo solto, concedida ordem em Habeas Corpus (págs.161/167). Diante da pena e regime aplicados, o réu poderá recorrer em liberdade.

GUTEMBERG respondeu preso ao processo (conversão da prisão em flagrante em preventiva às págs.73/76). Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal. Presente o fumus commissi delicti, consubstanciado nas declarações dos policiais civis, na delação do corréu e na presente condenação. O periculum libertatis evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA da conduta imputada ao acusado - crime equiparado a hediondo, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas, pois GUTEMBERG dedica-se à prática ininterrupta de crime de tráfico de drogas. É reincidente específico.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado. Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio:

O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

O acusado ostenta condenações anteriores e irrecorríveis justamente pelo delito de tráfico de droga. É reincidente específico. Ainda cumpria a pena anterior por

delito desta natureza, em regime aberto, quando voltou a delinquir. Não há dúvida de que adota a prática da mercancia ilícita como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir.

Não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que assim ostenta periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar. Não teriam idêntico efeito da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado GUTEMBERG na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória em favor de GUTEMBERG.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga em favor da União.

De plano, não impugnados os laudos periciais:

a) e não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

b) autorizo a destruição da pochete. Oficie-se à autoridade competente. Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, os acusados para que proceda ao pagamento;

d) Providencie-se a transferência do numerário apreendido nos autos para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito (comprovante de depósito juntado a pág. 118).

Custas pelos réus no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA